

1501463-66.2020.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1501463-66.2020.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 14 de fevereiro de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501463-66.2020.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

PAULO ROBERTO BITENCOURT VIEIRA e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Paulo Roberto Bitencourt Vieira e Rafael Bitencourt Pereira, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) e art. 35, caput, da LD (fls. 199/201).

Determinou-se o processamento (fls. 202/204).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 245 e 247), apresentou resposta escrita (fls. 250/252 e 253/259). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 4 de abril de 2021 (fls. 261/264) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 367 e 369).

Em audiência (fls. 379/380 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum e outras seis pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (fls. 442/445), o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal (desclassificação criminal), argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático previsto no art. 28 da LD e a autoria delitiva, porém, em relação ao contexto fático previsto nos arts. 33 e 35 da LD, não existe prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD (fls. 447/450 e 453/454).

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade objetiva do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 08/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/14 [AEA]), dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 16/18) e definitivo (fls. * [LPTox]), dos laudos periciais telefônicos (fls. 287/289, 310/312, 319/327, 328/336, 337/339 e 340/345 [LPTels]) e dos laudos periciais dos instrumentos do fato (fls. 284/286 e 313/318 [LPIFs]), ressalvado o elemento subjetivo (dolo), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha André Luiz Antunes, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "receberam denúncia anônima informando que Paulo iria na casa de Rafael fazer acerto de venda de entorpecente e abastecê-lo com mais drogas para venda. Diligenciaram para o local dos fatos e quando viraram na Avenida Joaquim Afonso, avistaram Paulo na porta da casa de Rafael, sendo que Paulo estava na calçada e Rafael dentro do portão. Ao verem a guarnição, Paulo imediatamente entrou em seu carro e empreendeu em fuga e Rafael entrou em sua residência. Os policiais acompanharam Paulo e obtiveram êxito em abordá-lo, sendo que em busca pessoal foram localizados 01 trouxinha de maconha e 01 cigarro do mesmo entorpecente já pronto para consumo. Em busca no veículo que Paulo dirigia, localizaram a quantia de R\$ 4.857,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais), 01 aparelho celular e duas máquininhas de cartão. Quando Paulo percebeu que seria conduzindo, pegou seu aparelho celular que estava sobre o capô da viatura e arremessou no chão, quebrando o visor do aparelho. Retornaram para a casa de Rafael e tiveram a entrada franqueada pela mãe do mesmo e abordaram Rafael na varanda da casa. Em revista pessoal, foram localizados 01 cigarro de maconha pronto para consumo. Em busca no quarto de Rafael, foi encontrado em seu guarda roupas, mais especificamente no bolso de uma bermuda a quantia de R\$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais), além de 05 aparelhos celular sobre a cômoda do quarto de Rafael. Por ambos serem conhecidos nos meios policiais e já terem passagem pelo crime de tráfico de drogas, foi proferida voz de prisão a ambos e eles conduzidos

até este Plantão Policial." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Vander Luís Apparicio, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "receberam denúncia anônima informando que Paulo iria na casa de Rafael fazer acerto de venda de entorpecente e abastecê-lo com mais drogas para venda. Diligenciaram para o local dos fatos e quando viraram na Avenida Joaquim Afonso, avistaram Paulo na porta da casa de Rafael, sendo que Paulo estava na calçada e Rafael dentro do portão. Ao verem a guarnição, Paulo imediatamente entrou em seu carro e empreendeu em fuga e Rafael entrou em sua residência. Os policiais acompanharam Paulo e obtiveram êxito em abordá-lo, sendo que em busca pessoal foram localizados 01 trouxinha de maconha e 01 cigarro do mesmo entorpecente já pronto para consumo. Em busca no veículo que Paulo dirigia, localizaram a quantia de R\$ 4.857,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais), 01 aparelho celular e duas máquininhas de cartão. Quando Paulo percebeu que seria conduzindo, pegou seu aparelho celular que estava sobre o capô da viatura e arremessou no chão, quebrando o visor do aparelho. Retornaram para a casa de Rafael e tiveram a entrada franqueada pela mãe do mesmo e abordaram Rafael na varanda da casa. Em revista pessoal, foram localizados 01 cigarro de maconha pronto para consumo. Em busca no quarto de Rafael, foi encontrado em seu guarda roupas, mais especificamente no bolso de uma bermuda a quantia de R\$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais), além de 05 aparelhos celular sobre a cômoda do quarto de Rafael. Por ambos serem conhecidos nos meios policiais e já terem passagem pelo crime de tráfico de drogas, foi proferida voz de prisão a ambos e eles conduzidos até este Plantão Policial". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

As testemunhas Leandro Ribeiro de Oliveira, Vanessa Vargas da Conceição, Rafael Ramos e Erinaldo Matos Correia, que são conhecidas do acusado Paulo Roberto Bitencourt Vieira, declararam, em Juízo, que: "Não presenciaram o contexto fático processado. Relataram, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

A testemunha Everaldo Bitencourt, que é primo dos acusados, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade dos acusados."

A informante Ivanilde Bitencourt Cruz, que é mãe do acusado Rafael Bitencourt Pereira e prima do acusado Paulo Roberto Bitencourt Vieira, declarou, em Juízo, que: "no dia dos fatos estava na sua casa. Disse que os militares abordaram Paulo próximo a sua casa. Os policiais entraram na casa e acharam um "baseado". Disse que o dinheiro encontrado na sua residência é dela, pois vende enxoval. No dia também fui detida, mas não fui ouvida. Afirmou que foi apresentada nota aos policiais, mas não juntaram no inquérito."

* Sr. Paulo Roberto Bitencourt Vieira:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 04).

Negou a prática criminosa.

A oitiva foi assistida por advogado.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Alegou que tem uma barbearia, tem uma loja e é operador de empilhadeira. No salão, às vezes, o pagamento era feito por máquina de cartão. Disse não ter problema pessoal com os policiais. Há 4 anos foi condenado por tráfico. No dia dos fatos, estava em frente a casa do Rafael e a viatura passou. Então, subiu de encontro com eles e não empreendeu fuga. Os policiais o abordaram e apreenderam um cigarro de

maconha. Ficou nervoso e acabou quebrando seu celular [comportamento, deveras, estranho, pondero, típico de quem esconde algo!]. Os policiais encontraram o valor de R\$ 4.800,00 dentro de um envelope do Bradesco e máquinas de cartão. Os policiais disseram que ele teria ido até a casa do Rafael para abastecer. Disse que leva consigo as máquinas de cartão depois que fecha a barbearia."

* Sr. Rafael Bitencourt Pereira:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 06).

Negou a prática criminosa.

A oitiva foi assistida por advogado.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Alegou que tem problema pessoal com o policial André, que o ameaçava de prisão. No dia, estava em sua casa e Paulo estava com o dinheiro para comprar roupa. Os policiais ingressaram em sua casa e encontraram um "baseado" para seu uso pessoal, bem como um valor em dinheiro, que pertencia a sua genitora. Os celulares apreendidos eram das pessoas da minha família. Disse que não passaram na residência do Paulo para verificar se tinha algo ilícito."

Pois bem.

Do tráfico ilícito de drogas.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) - ou querelante - e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua.

E, nesse aspecto, o Parquet, posto perquirir, não provou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o oferecimento e o recebimento da denúncia em face dos acusados, consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 - Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha).

No entender deste magistrado, o contexto fático conhecido e provado (os acusados, por ocasião dos fatos, traziam consigo drogas indevidamente) não autoriza, por indução, concluir-se pelo elemento subjetivo descrito na denúncia (vontade de participar da produção e da circulação de drogas [intuito mercantilista]), o que caracterizaria o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD).

Trata-se de dado elementar duvidoso.

Nessa perspectiva, os agentes de segurança pública, os quais têm o meu respeito e consideração, não trouxeram, ao serem inquiridos em Juízo, dados suficientes de que as drogas, no caso vertente, destinavam-se ao consumo alheio (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005997-69.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. IVO DE ALMEIDA, V.U., j. 20/05/2019; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000163-02.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 7/06/2018; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003239-20.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. NEWTON NEVES, V.U., j. 08/08/2019).

Ao contrário, existe prova suficiente da existência do crime de porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), seja pela observação forense do que ordinariamente acontece (quod plerunque accidit), seja pelas circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos).

Assim, convenço-me que os acusados, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, traziam consigo, para consumo pessoal, as drogas apreendidas (AEA), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

De rigor, pois, a desclassificação criminal.

Eis o meu convencimento.

Da associação para o tráfico ilícito de drogas.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) - ou querelante - e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua.

E, nesse aspecto, o Parquet, posto perquirir, não provou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face dos réus pela prática do contexto fático previsto no art. 35, caput, da LD (associação para o tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

Pontifico.

Nos termos do art. 35, caput, da LD, "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas", configura o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas.

O tipo objetivo, vejam, é "associarem-se" (reunirem-se, juntarem-se, com ânimo de associação, de caráter duradouro e estável) "duas ou mais pessoas" (plurissubjetividade) "para o fim de praticar" (elemento subjetivo específico

[finalidade associativa]), "reiteradamente ou não" (habitualidade ou eventualidade executiva), "qualquer dos crimes" apontados com taxatividade pela Lei de Drogas (finalidade associativa).

O que diferencia o crime de associação criminosa específica do tráfico ilícito de drogas (art. 35 da LD) do concurso de pessoas (art. 29 do CP) é o elemento subjetivo (*animus*) dos sujeitos ativos do crime.

Exige-se, para a configuração do crime de associação criminosa, a demonstração concreta do vínculo de estabilidade e permanência (associatividade), diferentemente do concurso de pessoas.

Não é suficiente a união ocasional, eventual e episódica.

Para determinar se a reunião era, ou não, eventual, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias comportamentais dos sujeitos ativos do crime (critério objetivo), e não ao conhecimento dos agentes policiais a respeito da fama deles (odioso critério subjetivo).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. *Pensar bem nos faz bem!*: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não se exige, para a configuração deste crime autônomo, a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o caráter associativo da convergência de vontades (*animus manendi*, intenção de permanecer, ânimo associativo) de se praticar um número indefinido de crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 22/01/2020, p. 06), como, por exemplo (*verbi gratia*), a habitualidade do contato dos réus (periodicidade), a confluência dos diálogos (correspondência) e o conteúdo das comunicações (*thema*).

Não existe prova suficiente (bastante, necessária) de que se tratava de reunião estável e permanente (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 12/08/2019, p. 11).

Nesse aspecto, esclareço, a denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva, mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte) e, desse modo, o contato (interação) dos réus, em que pese a relação familiar (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501130-17.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 10/05/2021, p. 06/07 ["... nada se investigou sobre mais do que a coautoria, não sendo bastante a mera suspeita de associação permanente, ainda que se tome em consideração o fato de os dois estarem praticando o tráfico de drogas no âmbito familiar."]), era meramente ocasional ou episódico.

Não era um verdadeiro pacto associativo, acerto.

Não está evidente a intenção de reiteração delituosa.

Descaracterizada, pois, a associação criminosa específica.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 28, caput, da LD.

Consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União (art. 1º, parágrafo único, da LD).

Em outras palavras, dependência – física ou psicológica – é o estado de quem não consegue desligar de um hábito, especialmente de um vício (prejudicialidade).

Por se tratar de conduta que compromete os elementos do dolo – cognitivo ou intelectual [representação] e volitivo – (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001193-87.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE, V.U., j. 02/09/2019, p. 13/14), a clara ofensividade (gravidade) e periculosidade da conduta, independentemente da quantidade da droga, impedem, por assim reconhecer (STF – 2ª Turma – HC 115.246/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/05/2013), a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, da parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas, LD), não cominou pena privativa de liberdade para o crime de porte ou cultivo ilícitos de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput e § 1º, da LD), cujo preceito secundário passou a cominar medidas educativas (novatio legis in melius).

As medidas educativas, atendendo-se aos critérios dos arts. 42 da LD e 59 do CP (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e a Defesa.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Porte ou cultivo ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28 da LD):

I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - comparecimento a programa ou curso educativo -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), separadamente.

Do réu Paulo Roberto Bitencourt Vieira

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 13/10/2020

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

215-95/2016

03/06/2016

22/06/2018

62

*

Antecedentes

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06), inicio a dosimetria.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, os antecedentes são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a medida-base em (i) advertência sobre os efeitos das drogas, (ii) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD), e (iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD).

Dos antecedentes: A parte ré apresenta dados desabonadores – ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) – da vida pregressa.

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ – Terceira Seção – RESP 1.794.854/DF – Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP (STF – Plenário – RE 593.818/SC – Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, V.M., j. 17/08/2020), porque, segundo o Relator, trata-se de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a medida provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a medida provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a MEDIDA DEFINITIVA em (i) advertência sobre os efeitos das drogas, (ii) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD), e (iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 5 (cinco) meses (art. 28, § 3º, da LD).

Do réu Rafael Bitencourt Pereira

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, as circunstâncias não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a medida-base em (i) advertência sobre os efeitos das drogas, (ii) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) mês (art. 28, § 3º, da LD), e (iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 1 (um) mês (art. 28, § 3º, da LD).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a medida provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a medida provisória nos marcos fixados até então.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a MEDIDA DEFINITIVA em (i) advertência sobre os efeitos das drogas, (ii) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) mês (art. 28, § 3º, da LD), e (iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 1 (um) mês (art. 28, § 3º, da LD).

2.4 Da prestação de serviços à comunidade

A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitalares, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas (art. 28, § 5º, da LD).

2.5Da garantia do cumprimento das medidas educativas

Para garantia do cumprimento das medidas educativas aplicadas a que injustificadamente se recusa a parte ré, poderá o Estado-Juiz, de acordo com o art. 28, § 6º, da LD, submetê-la, sucessivamente, a admoestação verbal e multa (art. 29 da LD).

2.5Dos efeitos da condenação

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, a, do CP, NÃO RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos do crime apreendidos com a parte ré (AEA), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), não consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, NÃO RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), não constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas (TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001366-14.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. NILSON XAVIER DE SOUZA, V.U., j. 17/04/2020, p. 09).

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento nos arts. 383, caput, e 387, caput, do CPP, (1.) a parte ré PAULO ROBERTO BITENCOURT VIEIRA, portadora do RG n. 71.632.939 – SSP/SP, como incurso no art. 28, caput, da LD, às medidas educativas de (i) advertência sobre os efeitos das drogas, (ii) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 2 (dois) meses (art. 28, § 3º, da LD), e (iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 5 (cinco) meses (art. 28, § 3º, da LD); e (2.) a parte ré RAFAEL BITENCOURT PEREIRA, portadora do RG n. 63.652.392 – SSP/SP, como incurso no art. 28, caput, da LD, às medidas educativas de (i) advertência sobre os efeitos das drogas, (ii) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) mês (art. 28, § 3º, da LD), e (iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 1 (um) mês (art. 28, § 3º, da LD); por fim, absolvê-la, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da prática do contexto criminoso denunciado (arts. 33 e 35, capita, da LD), pois não existe prova suficiente para a condenação.

3.1Da advertência cominada

A parte condenada deve ser submetida à medida de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I, da LD).

Para fins da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD), consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União (art. 1º, parágrafo único, da LD).

Advertência: Tanto as drogas lícitas (bebidas alcoólicas, cigarros etc.) quanto as ilícitas (art. 1º, parágrafo único, da LD) (maconha, cocaína, crack, heroína, ácido lisérgico [LSD], ecstasy etc.) podem causar diversos danos mentais e físicos aos seres humanos.

Entregue-se pessoalmente à parte condenada, devidamente qualificada, cópia desta sentença que, em atenção à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade da sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF), valerá, excepcionalmente,

como termo de advertência (aviso e censura) sobre os efeitos das drogas (art. 28, I, da LD).

Depreque-se, se for o caso, a advertência.

3.1.1 Da declaração de extinção da punibilidade

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, computando-se o tempo de prisão provisória, desde o dia 13 de outubro de 2020 (fls. 01) (TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000950-17.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GUILHERME DE SOUZA NUCCI, V.U., j. 05/02/2021, p. 05/06), às medidas educativas, com prazos mensais, aplicadas (detração imprópria), DECLARO, nos termos do art. 107, caput (cumprimento), do CP e art. 61, caput, do CPP, extinta a punibilidade da parte condenada, devidamente qualificada, com a observação do disposto no art. 202 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal, LEP).

3.1.2 Das providências preliminares

Expeça-se, nos termos dos arts. 409 e 410 das NJCGJ, alvará de soltura clausulado em favor da parte ré; dispensada, conseqüentemente, a expedição de guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3 Da pena de multa

Não há cominação.

3.4 Das comunicações

Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (art. 809, VI [sentenças de mérito], do CPP e arts. 393, V, e 472, I, das NJCGJ [Comunicado CG n. 464/2019]), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para efetivação.

Comunique-se, nos termos dos arts. 662 e 664 do CPP, à E. Câmara de Direito Criminal competente para julgar o habeas corpus, enviando-lhe, por endereço eletrônico (e-mail), cópia desta sentença.

3.5 Da certidão de honorários advocatícios

Não há certidão a ser expedida.

3.6 Das coisas apreendidas não confiscadas

A contar da data em que transitar em julgado a sentença final, as partes e eventuais interessados (lesado ou terceiro de boa-fé) deverão pedir (reclamar, requerer), no prazo de 90 (noventa) dias, a restituição dos bens móveis (art. 82 do CC) lícitos (não proscritos pelas Normas do Direito Brasileiro) apreendidos – não confiscados (arts. 119, 121 e 124 do CPP), esclareço – (cf. Auto de Exibição e Apreensão), desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

O reclamante deverá provar o seu direito de propriedade.

Com o pedido de restituição dos objetos apreendidos (requerimento devidamente instruído com a prova do direito de propriedade, advirto), abra-se vista dos autos ao Ministério Público (art. 120, § 3º, do CPP).

Se, dentro no prazo de 90 (noventa) dias, os bens apreendidos não forem reclamados (silêncio) ou não pertencerem à parte ré (não comprovação da propriedade), os mesmos serão, se for o caso, vendidos em leilão (art. 123 do CPP), depositados (art. 123 do CPP) ou, aplicadas as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 374 do CPC), inutilizados.

Registre-se eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 15 de fevereiro de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)